

1500064-16.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, sendo que avistaram o réu agachado próximo a um barranco. Ao ver a equipe, ele saiu correndo, mas foi abordado. Em sua posse, encontraram parte das drogas. Ele confessou informalmente o tráfico e disse que não tinha vendido nenhuma porção. Ele também apontou o local onde foi apreendido o restante das drogas, que eram idênticas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500064-16.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000033

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007014/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22339618 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 77/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2007014 - 02º D.P. PIRACICABA, 77/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES DANILO SARCEDO

Réu Preso

Aos 24 de maio de 2022, às 15:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. JOSÉ EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: CHARLES DANILO SARCEDO - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JUNIOR - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC CESAR EDUARDO BOTTENE - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JUNIOR e GC CESAR EDUARDO BOTTENE.

Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, por ele foi dito que aditava

a denúncia, conforme manifestação a seguir:

"Mma. Juíza, diante dos depoimentos dos guardas municipais, adito a denúncia, para que dela conste que a infração foi cometida nas imediações de equipamento público onde se desenvolvem atividades recreativas e esportivas, tratando-se de uma praça municipal com brinquedos para crianças e campo de futebol de areia, onde, por ocasião dos fatos, havia crianças brincando e jovens jogando bola. Em razão do aditamento, o réu está incurso no art. 33 c.c. o art. 40, inc III, da Lei nº 11.343/06".

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito:

"Encerrada a instrução, o Ministério Público pretende o aditamento da denúncia para que ao acusado sejam imputada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. A Defensoria Pública se opõe ao aditamento pretendido pelo Parquet. Ora, não se trata de fato novo, e não foi minimamente comprovado, não havendo justa causa para o seu recebimento (CPP, art. 395, III). Nesse contexto, todos os fatos já eram de conhecimento da acusação desde o início da persecutio criminis, não tendo sido descoberto por conta de elemento de prova novo, sendo certo que o Parquet poderia, desde o início, efetuar pesquisas na rede mundial de computadores para verificar se o local da abordagem era, de fato, próximo de uma praça. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que "[...] se o aditamento teve por supedâneo fato novo, não conhecido por ocasião do oferecimento da denúncia, o seu recebimento não constitui constrangimento ilegal" (TJSP – HC – Rel. Denner de Sá – RT 513/395). Todavia, no presente caso, a situação é diversa. O pretendido aditamento viola o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, ao oferecer sua a denúncia e optar por não incluir o fato que já era de seu conhecimento na exordial, o Parquet deu ensejo ao arquivamento tácito. E, conforme se infere do art. 18 do Código de Processo Penal, tal fato só poderá ser incluído na imputação em caso do surgimento de elemento de prova nova, o que não é o caso, como já dito. Na mesma direção, a Súmula 524 do STF dispõe que "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas." Sobre o arquivamento tácito, leciona Aury Lopes Jr.: [...] se o MP deixar de incluir na denúncia algum fato ou indiciado, sem expressa fundamentação, terá se operado a omissão que o constitui. Assim, se o juiz também não se manifestar sobre o fato ou sujeito, estará consolidado o arquivamento. Daí por que o arquivamento é, na verdade, tácito, decorrendo da omissão do MP e da inércia do juiz (que poderia ter utilizado o art. 28, remetendo para o procurador-geral, caso não concordasse) (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 316). Na mesma linha é a lição de Afrânio Silva Jardim e Pierre de Amorim: Entende-se por arquivamento implícito o fenômeno de ordem processual decorrente de o titular da ação penal deixar de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação ou justificção deste procedimento. Esse arquivamento se consuma quando o Juiz não se pronuncia na forma do art. 28 com relação ao que foi omitido na pela acusatória. Melhor seria dizer arquivamento tácito (JARDIM, Afrânio Silva; AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de. Direito processual penal: estudos e pareceres. 13. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 198). Inclusive, na presente audiência, a Defensoria efetuou breve pesquisa junto ao Google Maps e constatou que, embora exista uma área verde no local (não existem imagens do Google Street View), não foi possível visualizar os equipamentos mencionados pelos Guardas, como aparelhos de exercícios ou campo de futebol, sendo que se trata o local, somente, de uma área de mata, sem maiores relevâncias. Assim, a Defensoria Pública requer sejam mantidos os fatos tais como descritos na denúncia originariamente, rejeitando-se o pretendido aditamento".

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

"Não consta dos elementos de prova que instruíram o inquérito, seja do depoimento dos guardas municipais, seja do boletim de ocorrência, que os fatos se passaram em local onde há brinquedos e quadra esportiva, tratando-se, pois, de fato novo. Assim, recebo o aditamento à denúncia ora formulado. Procedam-se as anotações, correções e inclusões necessárias no sistema informatizado".

Dada a palavra às partes, por elas foi dito nada tinham a opor ou a requerer ante ao recebimento do aditamento da denúncia.

Após, o réu CHARLES DANILO SARCEDO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "CHARLES DANILO SARCEDO, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 09h29min, na Rua Mercúrio, nº 59, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e tinha em depósito, 6,8g de cocaína, na forma de pedras ("crack"), distribuídos em 45 invólucros, e 169,8g de Cannabis sativa L., erva vulgarmente conhecida como "maconha", distribuídos em 87 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 169/172) O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A denúncia foi aditada em audiência nos seguintes termos: "diante dos depoimentos dos guardas municipais, adito a denúncia, para que dela conste que a infração foi cometida nas imediações de equipamento público onde se desenvolvem atividades recreativas e esportivas, tratando-se de uma praça municipal com brinquedos para crianças e campo de futebol de areia, onde, por ocasião dos fatos, havia crianças brincando e jovens jogando bola. Em razão do aditamento, o réu está incurso no art. 33 c.c. o art. 40, inc III, da Lei nº 11.343/06". A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 25/26, foto a fl. 31/37 e laudo pericial a fls. 195/197. CHARLES, sendo interrogado, negou os fatos. Disse que passava pelo local. Estava de "saidinha" e optou por não voltar à prisão após uma briga de família. Foi abordado em local diverso, no bairro Jaraguá. Foi abordado porque "deu uma ciscada". Como estava foragido, foi falsamente acusado da prática ilícita. Assinou um livro preto no Plantão Policial e jogado no "corró". De toda sorte, a autoria delitativa foi comprovada. Os guardas municipais relataram que surpreenderam o réu em conhecido ponto de tráfico, uma praça com equipamentos recreativos e esportivos. Ao visualizar a patrulha ele se colocou em fuga. Alcançado e abordado, tinha em seu poder uma sacola com porções de droga. No local onde foi inicialmente visto, havia as demais porções de droga (discriminam). O réu admitiu a propriedade dos entorpecentes. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. Neste panorama, devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é multirreincidente e ostenta maus antecedentes (certidão a fls. 173/179), razão pela qual se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de

entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreram de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe à Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da

ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Francisco, GCM, declarou que passavam pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, sendo que avistaram o réu agachado próximo a um barranco. Ao ver a equipe, ele saiu correndo, mas foi abordado. Em sua posse, encontraram parte das drogas. Ele confessou informalmente o tráfico e disse que não tinha vendido nenhuma porção. Ele também apontou o local onde foi apreendido o restante das drogas, que eram idênticas àquelas que foram apreendidas em poder dele. O acusado estava sozinho, mas algumas pessoas estavam na praça. Um barranco separava a praça do local onde o acusado estava. Existem três acessos à praça e um deles é o local onde o réu estava. A testemunha Cesar, GCM, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro e, em um local conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu em um barranco. Ao ver a viatura, ele saiu correndo com uma sacola plástica na mão. Acompanharam o acusado por alguns metros e o abordaram. Na sacola, encontraram 45 pedras de crack e 08 porções de maconha. Ao ser indagado, ele indicou o local onde existiam mais drogas escondidas, onde encontraram uma pochete contendo outras 79 porções de maconha. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu estava próximo a um parque infantil, onde existem alguns brinquedos para crianças e um campo de futebol de areia. O parque fica no meio das casas e o barranco é uma caminho que usam para acessar a rua de cima. O local é uma praça municipal. Onde o réu estava é um dos acessos. O réu, em interrogatório, declarou que estava retornando da casa da sua mãe quando foi abordado pelos Guardas. Apenas ficou receoso quando viu a viatura porque estava foragido (não retornou da saída temporária). Não portava entorpecentes. Não estava abaixado quando foi abordado. Estava no bairro Jaraguá, na Rua Dona Anésia. Não possui nenhuma praça no local. Não conhecia os Guardas. Eles somente disseram que iriam levá-lo porque estava foragido. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito

criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, a maior parte dos entorpecentes não estava sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E a suposta confissão informal

do acusado não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminoso), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente

é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência." (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição ("O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos", in Direitos Humanos - Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição do acusado, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes ou presidiários, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato de o denunciado ter sido surpreendido próximo a uma "área de lazer" (art. 40, III), circunstância baseada unicamente no depoimento das testemunhas ouvidas nos autos, não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

CHARLES DANILO SARCEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 09h29min, na Rua Mercúrio, nº 59, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e tinha em depósito, 6,8g de cocaína, na forma de pedras ("crack"), distribuídos em 45 invólucros, e 169,8g de Cannabis sativa L., erva vulgarmente conhecida como maconha, distribuídos em 87 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina pela cidade quando no local acima avistaram o acusado em atitude suspeita, agachado e próximo de um barranco. Ao avistar a viatura, empreendeu fuga com algo na mão, mas foi abordado próximo dali. Em revista pessoal, no saco plástico que Charles trazia na mão direita, havia 45 invólucros plásticos contendo "crack" e oito invólucros plásticos contendo maconha. Ao retornarem ao local onde o réu foi avistado, ele apontou onde haveria mais drogas, sendo encontradas, próximo a um barranco, 79 porções de maconha, embaladas da mesma forma que as demais.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 214) e apresentou defesa preliminar (fls. 218/222), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 223/225).

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia.

Na sequência, a denúncia foi aditada, para dela constar que a infração foi cometida nas imediações de equipamento público onde se desenvolvem atividades recreativas e esportivas, tratando-se de uma praça municipal com brinquedos para crianças e campo de futebol de areia, onde, por ocasião dos fatos, havia crianças brincando e jovens jogando bola, dando-se o réu como incurso no art. 33 c.c. o art. 40, inc III, da Lei nº 11.343/06.

Após a manifestação da Defesa, o aditamento foi recebido e o réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, pelas fotografias de fls. 31/37 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 195/197, que trouxe resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 39).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que estava vindo da casa da sua mãe.

Asseverou que estava em saída temporária e, em razão de ter brigado com a mãe do seu filho, não retornou ao sistema prisional. Alegou que foi abordado no bairro Jaraguá quando se dirigia para a casa do seu pai, na Rua Dona Anésia, defronte ao Supermercado Dia. Sustentou que, quando viu a viatura, "deu uma ciscada", porque estava foragido. Declarou que foi abordado, mas não tinha droga em seu poder e nunca mexeu com tráfico.

A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o guarda municipal Francisco narrou que passaram pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, e avistaram o réu sozinho, abaixado, perto de um barranco. Disse que, no momento em que viu a equipe, o réu saiu correndo, segurando uma sacola. Atestou que ele foi acompanhado e abordado. Com o réu, apreenderam 45 pedras de crack e oito porções de maconha. Indagado, ele admitiu que estava no local para praticar o tráfico, mas não tinha vendido ainda nenhuma porção.

Asseverou que perguntaram se havia mais drogas, ele falou que sim e apontou exatamente o local onde ele estava anteriormente abaixado, onde encontraram 79 porções maconha embaladas de forma similar às encontradas com ele. Informou que o local é uma praça, na qual há brinquedos e um campo de futebol. Aduziu que havia

crianças e jovens na praça no momento dos fatos.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal César.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: "Habeas Corpus - Tráfico de drogas- Pleito de revogação da prisão preventiva - Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade - Artigo 301 do CPP - Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante - Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência - Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Enfim, o fato de os guardas civis terem apreendido 45 pedras de "crack" e 08 porções de maconha em poder do acusado, mais outras 79 porções de maconha embaladas de maneira idêntica às encontradas com ele, escondidas próximas do barranco onde

ele foi visto agachado, conduz à certeza quanto a autoria.

Anoto que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo e tenha em depósito substância entorpecente.

Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, eis que as circunstâncias da apreensão evidenciaram que o tráfico era cometido nas imediações de uma praça, como atestaram os guardas, cujo depoimento, como já anotado, é válido como prova. E, como é sabido, o objetivo da lei é impedir, no máximo, a propagação da toxicomania em locais de maior concentração popular.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu ostenta Maus antecedentes (processo nº 0000254-03.2018 da 2ª Vara Criminal local e processo nº 0027627-72.2009 da 3ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 173/179). Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência (processo nº 0000123-47.2016 desta 4ª Vara Criminal local, processo nº 0004721-44.2016 e nº 0005700-69.2017, ambos da 1ª Vara Criminal local e processo nº 0005469-13.2015 da 3ª Vara Criminal local - cf. cert. de fls. 173/179), razão pela qual aumento a pena em um sexto, totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo. Não há circunstâncias atenuantes.

Com fundamento no art. 40, III, da Lei n. 11.343/0, aplico o aumento de um sexto, totalizando sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e 793 dias-multa. Não há causas de redução da pena.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de

Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu CHARLES DANILO SARCEDO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que se manifestará no prazo legal.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Recebo o recurso interposto.

2) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

3) Com a manifestação do Ministério Público ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para deliberações.

4) Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUIZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]